

1503479-59.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... dúvida da prática do crime de tráfico que lhe foi imputado, até porque o fato dela ser usuária não acarreta necessariamente a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra.

Sobre o tema, veja-se:

"TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503479-59.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266745/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 20563003 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5535/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2266745 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSICA FERNANDA DESIBIA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

JÉSSICA FERNANDA DESIBIA e MAICON ROGÉRO MARTINS estão sendo processados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Notificados às fls. 223 (Jéssica) e 242 (Maicon), os réus apresentaram resposta às fls. 229/234.

A denúncia foi recebida em 25 de janeiro de 2022 (fls. 249/250) e os réus foram citados às fls. 282 (Jéssica) e 287 (Maicon).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e os réus foram interrogados (fls. 289).

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação apenas da acusada Jéssica (fls. 289).

A defesa postulou a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o artigo 28 da Lei 11.343/06 (fls. 289).

É o relatório.
DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 6/9), boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), informações (fls. 38/42 e 140/141), fotografias (fls. 53/60) e laudos periciais (fls. 176/182 e 183/187), além da prova oral.

A autoria é certa em relação à ré Jéssica.

Em juízo, Maicon rechaçou a acusação. Disse que não tinha conhecimento de que havia drogas na residência (onde morava com Jéssica) e que parou de usar entorpecentes quando deixou o sistema prisional. Aduziu que trabalhava como servente de pedreiro e saía de casa todos os dias por volta das 6h30min. Jéssica estava desempregada. A ré Jéssica negou os fatos. Alegou que é dependente química há 14 anos e que estava usando drogas dentro de casa quando os policiais chegaram. O dinheiro apreendido era proveniente de um trabalho eventual que havia realizado. Seu marido não tinha conhecimento de que estava usando entorpecentes, pois o fazia quando estava sozinha em casa. A droga apreendida, destinada ao consumo próprio ("mesclado"), duraria cerca de uma semana.

Bruno, policial civil, relatou que os policiais receberam denúncias de que os réus praticavam o tráfico ilícito no local dos fatos, o que motivou a expedição de mandado de busca e apreensão. Durante o cumprimento da diligência, encontrou a ré sentada na calçada defronte à residência e, durante a abordagem, ela entregou à equipe uma porção de maconha, além de aproximadamente R\$50,00. Durante a busca no imóvel, localizou o restante da droga apreendida na janela da cozinha. Na casa ainda residiam o marido e o irmão dela. Ela disse que os entorpecentes seriam destinados ao uso próprio. Não conhecia os réus de antemão e não participou das investigações que precederam a expedição do mandado de busca.

Evandro, policial civil, confirmou a narrativa de seu colega e acrescentou que as investigações tiveram início após denúncias que envolviam "Vitão" e os réus. Durante as investigações, disse que chegou a passar algumas vezes defronte ao imóvel, todavia ressaltou a dificuldade de realizar campanhas naquele bairro, tendo em conta que até mesmo as viaturas descaracterizadas são conhecidas da população. Durante o cumprimento do mandado de busca, Maicon não foi localizado. Soube pela equipe que ficou no local que "Vitão" ali esteve, mas fugiu ao perceber a presença da polícia.

Como se vê, as provas são suficientes para condenação da ré Jéssica.

Jéssica alegou ser usuária de "mesclado" (mistura de crack e maconha), mas em sua residência também foi apreendida cocaína, além de embalagens usualmente utilizadas no comércio ilícito, cuja posse não foi justificada pela ré.

A alegação da ré de que estaria usando drogas dentro de casa foi rechaçada pelo relato do policial Bruno, que afirmou tê-la abordado na calçada, na posse de maconha e de dinheiro.

As denúncias que antecederam as investigações, as circunstâncias da diligência, a variedade de drogas apreendida, a ausência de segura comprovação de atividade

lícita por Jéssica (que não estava trabalhando na oportunidade, embora fosse dia útil) não deixam dúvida da prática do crime de tráfico que lhe foi imputado, até porque o fato dela ser usuária não acarreta necessariamente a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra. Sobre o tema, veja-se:

“TOXICO – Tráfico – Absolvição – Inadmissibilidade – Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio – Prova colhida que direciona-se nesse sentido – Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância – Condenação mantida – Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 – Ribeirão Preto – 4ª Câmara Criminal – Relator: Bittencourt Rodrigues – 22.08.00 – v.u.).”

Os policiais civis apresentaram narrativas harmônicas a respeito das circunstâncias que motivaram a diligência, do encontro dos entorpecentes e do dinheiro em posse da acusada. E não há qualquer elemento capaz de afastar as sobreditas versões, até porque a ré informou que sequer os conhecia.

A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 – 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator Willian Campos – julgado em 27 de maio de 2014 – votação unânime).

O fato de Jéssica não ter sido surpreendida no exato momento da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que, como cediço, elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal.

Nesta senda, decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“TÓXICOS – TRÁFICO – Consumo – Prática de algum ato de tráfico ou “traditio” – Inexigibilidade – Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente – Suficiência”(…)” (TJSP – Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 – São José dos Campos – 6ª Câmara Criminal – Relator Marco Antonio – J. 17.05.2007 – v.u). Voto nº 5.767. “TÓXICOS – Tráfico – Caracterização – Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto – Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (…)”(TJSP – Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 – Sorocaba – 5ª Câmara Criminal – Relator Pinheiro Franco – J. 20.09.2007 – v.u). Voto nº 9.739.

Assim, quanto à ré Jéssica, a condenação é medida que se impõe.

No tocante ao réu Maicon, todavia, a solução é diversa.

Embora as notícias que ensejaram a diligência revelem indícios contra Maicon, as provas não são suficientes para afastar, com segurança, a sua negativa.

Assim, e considerando a manifestação do próprio titular da ação penal em alegações

finais, a ação deve ser julgada parcialmente procedente para o fim de absolver o réu Maicon e condenar apenas a ré Jéssica pelo crime narrado na denúncia.

Parcialmente procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, verifico que, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser majorada, considerando a alta potencialidade lesiva de parte do entorpecente apreendido ("crack"), substância altamente nociva e viciante. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Na segunda fase, presente a agravante prevista no artigo 61, II, "j", CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo – ressaltando-se, sobre ela, conforme já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"), além da reincidência, que é específica (fls. 211/213 – Proc. 0023624-26.2016.8.26.0032). Assim, majoro a reprimenda para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.

Na terceira fase, a reincidência da ré enseja o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Assim, a reprimenda acima fixada torna-se definitiva, à mingua de outras causas de aumento ou de diminuição.

Considerando a reincidência e os motivos esposados na primeira fase, a pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, CP.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

"O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma

progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea “b”, da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, “caput”, da CF)”(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim, por entender que o art. 387, §2º, CPP viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade

difuso.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR a ré JÉSSICA FERNANDA DESIBIA à pena de 7 anos , 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e para ABSOLVER o réu MAICON ROGÉRIO MARTINS, com fulcro no artigo 386, VII, CPP.

A acusada respondeu ao processo preso e agora, com maior razão, não poderá apelar em liberdade, tendo em vista que continuam presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, notadamente a necessidade de impedir a reiteração criminosa. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra. Nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento do dinheiro apreendido. Custas na forma da lei. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P.I.C.

Jaú, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA